

YASMIN BINTI ABDUL RASHID
lwn
MOHD SHAHID BIN MOHD SEDED

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 24 Ogos 2022 bersamaan 26 Muharam 1444H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0060-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Encik Muhammad Firdaus Alhadi bin Abdullah
(Tetuan Firdaus Hadi & Associates)

Peguam Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 1/7/2022 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak keseluruhan perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes Permohonan No. 10207-038-0349-2021 pada 27/7/2022.

[2] Berdasarkan Notis Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Bahawa Mahkamah yang mulia ini membenarkan permohonan semakan di bawah seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 bagi menyemak semula berkenaan terma tiga (3) Penghakiman yang dibuat oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 27/6/2022.
- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan permohonan semakan ini bagi **mengubah keputusan terma 3 di Perintah** yang dikeluarkan pada 27/6/2022 sebagaimana terma kedua notis permohonan bagi kes Permohonan No: 10207-038-0349-2021.
- iii. Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah yang mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 13/9/2019 di Ampang, Selangor dan telah dikurniakan seorang anak perempuan iaitu Shanaya Meher binti Mohd Shahid (No. Mykid: 200912-10-0378). Sewaktu prosiding di Mahkamah Bicara, pihak-pihak masih dalam proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Ampang melalui kes Saman No: 10012-055-0187-2021.

[4] Pada 28/10/2021, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interim Hak Jagaan Anak di Mahkamah Bicara melalui Kes Permohonan No:10207-038-0349-2021. Selanjutnya pada 27/7/2022 YA Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut secara *inter-parte* sebagaimana terma-terma yang berikut:

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan pihak Pemohon berdasarkan seksyen 201(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama Shanaya binti Mohd Shahid (No. Mykid: 200912-10-0378) diserahkan kepada Pemohon (ibu) secara serta-merta selepas menerima Perintah ini sehingga ada Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan penjagaan anak atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Hak Bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Responden (ayah) pada hari Sabtu pukul 9.00 pagi dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum pukul 9.00 malam sebulan dua kali dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.*
- iv. *Kedua-dua pihak Pemohon dan Responden adalah ditegah daripada membawa anak tersebut keluar dari Malaysia dan ditegah anak tersebut dijaga oleh orang lain selain Pemohon dan Responden.*
- v. *Pihak Polis Diraja Malaysia atau Pegawai Berkuasa berkaitan hendaklah memastikan keharmonian Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.*
- vi. *Kos ditanggung oleh pihak-pihak.*

[5] Bagi maksud semakan ini, Pemohon hanya berhasrat untuk mengubah **terma ketiga** Perintah di atas sahaja.

ALASAN SEMAKAN

[6] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang dapat diringkaskan sebagaimana berikut :

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila memberikan hak bermalam sebulan dua kali kepada Responden sedangkan tiada sebarang permohonan oleh Pemohon atau Responden berkenaan hal tersebut di dalam mana-mana kertas kausa yang telah difailkan.
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila memberi hak bermalam tersebut tanpa mempertimbangkan usia anak tersebut yang baru berusia satu tahun sembilan bulan yang memerlukan penjagaan rapi daripada Pemohon selaku seorang ibu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[8] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[9] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

"In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice."

[10] Dalam kes tersebut, YA Hakim telah memberi panduan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[11] Sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[12] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[13] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks semakan ini, Peraturan 5 dan 7 yang berikut adalah relevan.

*5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku
kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).

[14] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[15] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan autoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara. Ia memberi maksud perintah atau penghakiman yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara ternyata telah membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[16] Bagi memutuskan persoalan tersebut, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Permohonan No. 10207-038-00349-2021 untuk menentukan sama ada ia menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah bersifat interim yang mewajarkan semakan dibuat.

[17] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui peraturan 5 dan 7 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [13] di atas, adalah jelas menunjukkan bahawa keputusan yang melibatkan kes-kes permohonan interim hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan telah berlaku atau tidak dalam kes permohonan tersebut.

[18] Selepas merujuk satu persatu alasan-alasan semakan yang dikemukakan sebagaimana pada perenggan [7] di atas, kami mendapati alasan utama adalah berkaitan kewajaran hak bermalam bersama anak diberikan kepada Responden. Dengan mengambil kira usia anak yang baru berusia hampir dua tahun.

[19] Sepanjang penelitian kami kepada alasan penghakiman, kami mendapati YA Hakim Bicara hanya memberikan ulasan ringkas berkenaan kewajaran hak bermalam tersebut adalah demi menjaga hubungan anak dengan Responden. Perkara ini dapat dilihat dalam ulasan YA Hakim Bicara yang kami petik sebagaimana berikut:

“[21] Mahkamah berpandangan hak bermalam diberikan kepada Responden walaupun anak tersebut masih belum mumayyiz bagi meraikan kehidupan anak tersebut bersama dengan Responden mengikut fakta kes yang dibentangkan dan demi untuk mengelakkan terputusnya kelangsungan hubungan yang telah wujud antara Responden dan anak tersebut.”

[20] Dalam keadaan tiada sebarang permohonan daripada Responden untuk mendapat hak bermalam, kami tidak menemui sebarang alasan lain yang diberikan oleh YA Hakim Bicara berkaitan kesediaan serta kemampuan Responden untuk diberikan hak tersebut.

[21] Pada hemat kami, dengan usia anak sedemikian maka pertimbangan tentang soal-soal perlindungan, keselamatan serta keperluan anak tersebut sebagaimana yang dibangkitkan dalam affidavit pihak-pihak sepatutnya turut diberikan perhatian oleh YA Hakim Bicara. Berdasarkan faktor-faktor ini kami berpandangan bahawa semakan ini adalah berasas.

[22] Berhubung dengan hak bermalam ini, sukacita kami merujuk kepada kitab *Al-Muktamad Fi Al-Fiqh AL-Syafie*, jilid 4 hlm. 315-316 karangan Prof. Dr. Muhammad Al-Zuhaili menyatakan –

وإن كان المميز أنثى، واختارت الأم، كانت عندها ليلاً ونهاراً، ويزورها الأب على العادة نهاراً، والتحرز عن الخلوة، ولا يطلب إخضارها عنده لتألف الستر والصيانة، وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير.

“Sekiranya kanak-kanak mumaiyiz itu perempuan dan dia memilih ibu, maka hendaklah ia tinggal bersama ibu malam dan siang. Manakala bapa hanya

datang melawatnya menurut adat pada waktu siang asalkan terhindar daripada khulwah (bersama ibu). Bapa tidak boleh meminta anak perempuan tersebut datang kepadanya. Ini bertujuan memudahkan perlindungan dan pemeliharaan. Dan begitu juga hukum apabila kanak-kanak di bawah jagaan ibu sebelum usia untuk membuat pilihan”.

[23] Berdasarkan ulasan yang telah kami berikan, dapatan kami adalah perintah YA Hakim Bicara pada terma ketiga perintah bertarikh 27/7/2022 secaranya materialnya bercanggah dengan prinsip undang-undang apabila memberikan hak bermalam kepada Responden tanpa justifikasi yang kukuh. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memperbetulkan kekhilafan ini dengan membuat pindaan kepada terma tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan ini **DITERIMA**.
2. Terma ketiga perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. 10207-038-0349-2021 bertarikh 27/7/2022 **DIPINDA** sebagaimana berikut:

Mahkamah memerintahkan hak melawat anak tersebut tanpa bermalam diberikan kepada Responden (bapa) pada setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat mulai jam 9.00 pagi sehingga 6.00 petang dengan Responden memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

